

1500495-80.2020.8.26.0062

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... do TJSP: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado a cumprir, em regime inicial semiaberto, pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, como incurso nos artigos 33, caput, da lei 11.343/06. Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou à paciente, primária e sem antecedentes criminais, o direito de recorrer em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500495-80.2020.8.26.0062 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500495-80.2020.8.26.0062

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2180918/2020 - DEL.POL.BARIRI, 8360369 - DEL.POL.BARIRI, 427/20/202 - DEL.POL.BARIRI, 433/20/202 - DEL.POL.BARIRI, 2180918 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque, supostamente, em horário incerto, porém na madrugada do dia 17 de março de 2020, em uma obra de edificação na Rua Tiradentes, 478, Centro, nesta comarca e cidade de Bariri/SP, mediante rompimento de obstáculo, teria subtraído, para si, diversos objetos de construção, avaliados em R\$ 1.080,44 (mil e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), pertencentes à vítima João Carlos Cardoso. Descreveu a inicial acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em horário incerto, porém na madrugada do dia 17 de março de 2020, em uma obra de edificação na Rua Tiradentes,

478, Centro, nesta cidade e comarca de Bariri/SP, RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 31, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) rádio-relógio, 02 (dois) cortadores de pisos (um de 75 cm e outro de 90cm), uma marreta de borracha e 02 (duas) de ferro, 03 (três) talhadeiras, um alicate torquês, 03 (três) níveis de mão, 01 (uma) trena de 7,5m, 01 (um) prumo, 01 (uma) caixa plástica de ferramentas e 01 (uma) extensão elétrica de 40m (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 08/09 e avaliação de fls. 14/24), avaliados em um total de R\$ 1.080,44 (mil e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) pertencentes a vítima JOAO CARLOS CARDOSO.

Segundo o apurado, o investigado, com o propósito de praticar crime patrimonial, a aproveitando-se do adiantado da hora, durante o repouso noturno, dirigiu-se ao local acima descrito e arrombou o tapume que separava a obra da calçada e impedia a entrada.

Já interior da obra, subtraiu os objetos indicados no primeiro parágrafo e deixou o local, sendo que toda a ação foi capturada por câmeras de segurança.

No dia seguinte, foi reconhecido em via pública pela testemunha ALEX DANIEL DE PAULA, que havia visto as imagens da câmera de segurança e logo chamou a polícia. Com a chegada dos Policiais Militares, foi realizada a abordagem, momento em que o indiciado admitiu ter praticado o furto e indicou o local onde havia escondido a res furtiva.

Parte dos objetos foram recuperados e entregues à vítima (fls. 08/09).

Ausentes as causas de rejeição do art. 395, do CPP, a denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2020 (fls. 71/72), e o réu foi citado para responder à acusação (art. 396, do CPP), apresentada às fls. 134/135 (art. 396-A, do CPP). Na mesma ocasião, foi decretada a prisão preventiva do réu.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397, do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 139/140).

Em instrução, foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação nos termos da denúncia. Teceu considerações quanto à dosimetria da pena, requerendo a exacerbação da pena-base em razão dos maus antecedentes; o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP); quanto à derradeira e última fase, pleiteou pela causa de aumento de pena referente ao crime ter sido cometido de madrugada (art. 155, § 1º, do CP). Por fim, postulou a aplicação do cumprimento de pena em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A Defesa, nas alegações finais orais, postulou pela absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, pelo não reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP); a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao delito ter sido cometido de madrugada (art. 155, §1º, do CP); bem como, por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

É o relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do fato está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 8/9 e 10/12), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14), tal como pela prova testemunhal produzida.

Com relação à autoria, o réu Rodrigo Cesar de Oliveira, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva. Declarou que estava passando perto do local dos fatos. Notou que parte da madeira que fechava o local estava aberta. Removeu a madeira para entrar. Declarou: "puxei um pouquinho e passei no vão, já que sou magrinho" (sic). Não se recordou com exatidão de todos os objetos furtados.

Pretendia vendê-los para comprar alimentos para sua mãe e drogas com o dinheiro que sobrasse. Devolveu os objetos à vítima quando abordado por ela. Está arrependido do que fez.

Em juízo, a vítima João Carlos Cardoso relatou que trabalhava em uma obra em construção, na esquina do semáforo. Chegou de manhã e não encontrou as ferramentas pertencentes à obra. Acionou a polícia e fez o boletim de ocorrência. Conseguiu imagens de câmeras de segurança, as levando para a delegacia, mas “a delegacia não conseguiu ler o pen drive” (sic). O réu foi pego e, no mesmo dia, recuperou a posse de seus pertences. Disse, ainda, que o acusado arrombou o tapume para entrar no local. Viu o réu entrando e saindo, por diversas vezes, pelas imagens da câmera de segurança. O tapume foi consertado por um vizinho, logo na parte da manhã. Não soube informar como o réu foi pego. Recuperou a maioria das suas ferramentas. Reforçou que a visibilidade das imagens da câmera de segurança estava boa, pois o local estava bem iluminado. Não conhecia o réu, o reconhecendo na delegacia devido às imagens. Não se recordou a respeito das vestimentas que o acusado usava no momento dos fatos. O tapume era fechado com madeira e pregos. Acessava as ferramentas por um portão lateral. Foram subtraídas ferramentas pequenas, como marreta, talhadeira, nível de mão, prumo e martelo. Também foram subtraídos equipamentos de parte elétrica, pertencentes a Alex.

Alex Daniel de Paula, ouvido como vítima, declarou que sua caixa de ferramentas foi furtada. Narrou que os fatos ocorreram de madrugada, pois soube pela gravação da câmera de segurança. Não conhecia o réu. Foi possível observar o acusado entrando pelo canto, em um vão aberto. “Mostra na câmera ele indo para trás, na Tiradentes contramão, levando os equipamentos. Ele foi duas vezes ainda, levando as ferramentas dos pedreiros e a minha” (sic). O réu levou as ferramentas do pedreiro e as suas. O local era fechado e o réu o invadiu, arrombando o tapume. O rosto do réu era visível “deu para reconhecer que ele usava um chapeuzinho, a barba dele e uma bolsa” (sic). Ficou sabendo onde o acusado residia. Na casa dele, o questionou quanto ao furto, ocasião em que foi revelada a localização dos objetos. De seguida, o réu foi preso pelos policiais. Não recuperou todas as suas ferramentas subtraídas. Foi o réu quem disse onde estava parte das ferramentas. As ferramentas estavam escondidas em lugares diferentes. Recontou que o réu entrou pelo vão que ele havia aberto, por meio de arrombamento do local. Os tapumes estavam pregados. Reconheceu o acusado como sendo o mesmo das imagens da câmera de segurança.

Por seu turno, a testemunha Claudionor José da Silva, policial militar, declarou que a polícia foi acionada no dia posterior ao furto. Tomaram conhecimento que Rodrigo era o autor dos fatos. Em duas equipes, seguiram para abordar o réu, que já era conhecido nos meios policiais. Indagado, o acusado disse que pretendia vender as ferramentas para comprar e fazer uso de drogas. Foi indicado onde estavam escondidos os objetos e, posteriormente, foram localizados. A vítima Alex reconheceu os materiais. O réu foi levado à delegacia policial, bem como confessou o delito. Alex os acompanhou até o local em que as ferramentas estavam escondidas, qual seja, atrás de um terreno. Reforçou que o réu era conhecido nos meios policiais por ser usuário de drogas e por realizar furtos.

Com efeito, a testemunha Devair Rocha, policial militar, em síntese, prestou os mesmos depoimentos da testemunha Claudionor. Acrescentou, ainda, que os fatos referentes à abordagem do réu ocorreram na parte da manhã.

Como se percebe, confrontando a confissão com os demais elementos de prova, analisados em conjunto (arts. 197 e 200, do CPP), noto que a autoria foi amplamente demonstrada, com a elucidação da dinâmica dos eventos pela prova oral.

O réu admitiu ter ingressado na obra em construção, por meio de arrombamento do tapume e, lá, subtraído os objetos descritos na denúncia. Parte da res furtiva foi localizada dentro de um terreno abandonado, perto da residência do réu, fato verificado pela vítima Alex e as testemunhas policiais, local indicado pelo próprio réu.

Nesse contexto, não subsiste nenhuma dúvida quanto à autoria do furto.

Presentes a materialidade e a prova (acima de dúvida razoável) da autoria, cumpre examinar as questões relativas à tipicidade.

É impositivo o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso

I, do Código Penal (furto qualificado: § 4º - a pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa).

Com efeito, houve desaparecimento dos vestígios quanto ao rompimento do obstáculo, já que o tapume foi recolocado, logo na manhã seguinte. Assim, a ausência de laudo se justifica pela impossibilidade de sua realização, o que não ocorreu por inércia dos órgãos de persecução penal, mas, como dito, pelo subsequente e célere desaparecimento dos vestígios.

Logo, aplica-se o art. 167 do CPP: “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”.

Como se vê, a prova testemunhal foi uníssona quanto ao rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, mediante o arrombamento do tapume, que ficava fechado com madeira pregada. Tal fato corroborado pela própria confissão do réu, que declarou “puxei um pouquinho e passei no vão, já que sou magrinho”. Dessa forma, incabível a desclassificação da imputação para tentativa de furto simples.

Em consonância com o entendimento ora exposto, cito a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto exige a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova quando o delito não deixe vestígios, tenham desaparecido ou, ainda, as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RESp 1899567/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Portanto, comprovada, pela prova testemunhal e confissão, impõe-se o reconhecimento da qualificadora.

Ademais, também é aplicável a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP, uma vez que o delito foi praticado durante a madrugada.

Nessa quadra, para que incida a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, basta a presença do critério objetivo (furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmara de segurança), mormente porque, no período noturno, a vigilância é menos eficaz.

Em situação semelhante, e que, inclusive, tratava de furto de ferramentas em obra em construção, não foi outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RESp 1721907, Min. Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação 01/06/2018.

No caso dos autos, a prova testemunhal foi inequívoca ao confirmar que era de madrugada quando o furto foi praticado, incidindo, assim, tal causa de aumento. Por fim, esclareço que, conforme entendem o STF (v.g. HC 130952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli) e STJ (v.g. HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), a causa de aumento do § 1º do art. 155, do CP pode ser aplicada tanto para furto simples como para o furto qualificado, inexistindo incompatibilidade. A posição topográfica do § 1º é fato que não impede sua aplicação para as situações de furto qualificado.

Ante todo o exposto, comprovadas a existência e a autoria do fato descrito na denúncia, e presentes a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é imperiosa a condenação.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, art. 42 da Lei 11.343 e arts. 59 e 68, ambos do CP.

Dosimetria e individualização da pena

Na primeira fase, considerando as disposições do art. 59, do CP, verifico que o réu

ostenta péssimos antecedentes, diante das condenações proferidas nos processos de nº 0010403-34.2003.8.26.0063, 0015437-15.2004.8.26.0302 e 0016567-74.2003.8.26.0302. As demais condenações, por fatos anteriores e com trânsito em julgado anterior ao fato deste processo, serão consideradas na segunda fase. Não há, nos autos, elementos hábeis para impor a negatização dos vetores referentes à personalidade do agente.

Incabível a negatização da conduta social (atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança), à míngua de elementos hábeis. No mais, condenações passadas não podem ser usadas para desvalorar personalidade ou conduta social, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1311636).

Os motivos do crime foram comuns à espécie.

As circunstâncias do crime (entendidas como aquelas de natureza objetiva, pertinentes ao tempo, duração, lugar e modo de prática do delito, e acessórias a ele) são normais à espécie.

As consequências são próprias da conduta.

Quanto ao comportamento do ofendido, a vítima em nada contribuiu para o delito.

A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com a culpabilidade como elemento caracterizador do crime) é normal à espécie.

Logo, presente um vetor negativo, aumento a pena em 1/6, e fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão; e 11 dias-multa, no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, à míngua de provas sobre as condições econômicas do réu).

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea "d") com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), referente à condenação no processo de nº 3002223-29.2013.8.26.0062 (0000887-46.2010.8.26.0062).

Logo, estabilizo a pena intermediária no patamar anterior.

Por fim, na terceira fase da fixação, está presente a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, uma vez que o delito foi praticado durante o repouso noturno. Não há causa de diminuição.

Assim, aumento a pena em 1/3; fixando a pena definitiva em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão; e 14 dias-multa, mantida no mínimo legal.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Em que pese o quantum da pena aplicada, não foram todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis quando da fixação da pena-base.

Vale salientar que, para a fixação do regime inicial, não se considera apenas o quantum da pena e a existência ou não de reincidência, mas também as circunstâncias judiciais. A comprovar o que se expõe, mutatis mutandis:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. (...). CONDENAÇÃO À 4 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO MAIS GRAVOSA. (...) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. (...) RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA. I - O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos tem o direito de cumprir a pena corporal em regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), caso as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe forem favoráveis. II - A imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso deve ser fundamentada, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (art. 33, § 3º, do CP) (...). IV - Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para o desconto da pena de reclusão." (HC 140441, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017).

No caso dos autos, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO,

observando-se assim o quanto previsto no § 3º, do artigo 33, do CP, o qual remete ao art. 59 do CP.

Registro que, considerando a gravidade concreta do delito (furto qualificado praticado mediante rompimento de obstáculo, em período noturno, e considerando as diversas condenações anteriores do réu, caracterizadoras de Maus Antecedentes e reincidência), regime inicial diverso não atenderia à reprovação e prevenção necessárias, conforme caput do art. 59 do CP.

Art. 387, §2º, do CPP

Não há falar em aplicação da regra prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (detração penal), porquanto o benefício não se confunde com progressão de regime. Ademais, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme entende o STJ (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe15/06/2018) e nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

Substituição da pena privativa de liberdade e "sursis"

Reincidente em crime doloso, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena (arts. 44, III, e 77, II, ambos do CP).

Logo, porque o sentenciado não preenche os requisitos dos arts. 44 e 77, do CP, deixo de substituir a pena fixada e conceder sursis.

Indenização mínima

Em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, é imperioso reconhecer a impossibilidade de fixação de valor mínimo da indenização a que alude o art. 387, IV, do CPP, pois não houve pedido nesse sentido na denúncia.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conforme art. 387 do CPP, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu ALEX GONÇALVES MERECI como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, às penas de 03 anos, 01 mês e 14 dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Status Libertatis": Inalterados os requisitos e pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, mantenho a segregação cautelar, inclusive para os fins do art. 316, parágrafo único, do CPP. Cumpre esclarecer, desde já, que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade (STJ. RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/05/2020, DJe 02/06/2020). Colhe-se da jurisprudência do TJSP: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado a cumprir, em regime inicial semiaberto, pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, como incurso nos artigos 33, caput, da lei 11.343/06. Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou à paciente, primária e sem antecedentes criminais, o direito de recorrer em liberdade. Prisão que perdurou durante toda a instrução processual. Desnecessidade de exaustiva fundamentação. Constrangimento ilegal não caracterizado neste posto. Necessária, apenas, a compatibilização da manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade. Determinação ex officio para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO." (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2123394-78.2021.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021). Expeça-se guia de execução provisória e o que mais for necessário para

compatibilização da segregação cautelar com o regime inicial ora determinado (recolhimento a estabelecimento prisional compatível com o regime fixado).

Transitada em julgado:

a) Intime-se o réu para pagamento da multa, expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) Oficie-se ao IIRGD;

c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Expeça-se certidão de honorários em favor em favor do Defensor Dativo, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do CPP).

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se a vítima (art. 201, §2º, do CPP).

Bariri, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA